

第 45 問

甲は、自己の親である A が多額の資産を有しているにもかかわらず、自分には一切の金銭的援助をしないことに腹を立てていたため、A を殺して、相続により、A の財産を得ようと考えた。もっとも、甲は、自宅で A を殺すと、自分が疑われると考え、A を散歩に誘い、河川敷で殺害することにした。甲が、計画どおり、A を河川敷まで連れて行き、用意していた包丁で刺殺したところ、たまたまその場を通りかかった B は、甲が A を殺害する様子を見ていた。

B は、これをネタにして甲から金員を脅し取ろうと考え、甲に対し、「このことをばらされたくなければ、1000万円持ってこい。親父の遺産が転がり込むんだから、そのくらい楽勝だろ。」などと申し向けた。甲は、これを聞いて、言うことを聞くしかないと考え、やむなくその場では「わかった、わかった。」と答えたが、1000万円を支払う意思はなかった。そこで、甲は、知り合いの C に対して、「B に脅されている。B を殺してくれたら500万円払うから、お願いできないか。」と言ったところ、C は、これを了承し、B 殺害の具体的な計画を自分で考えた上で、その計画どおりに B を殺害した。C から B を殺害した旨の報告を受けた甲は、C に500万円を払うのも惜しくなった。そこで、甲は、500万円を払うと言って、C を自宅へ呼び出し、毒薬の入ったお茶を飲ませて、殺害した。

甲の罪責について、論じなさい。

第1 Aに対する罪責

- 1 Aを殺害した行為について、強盗殺人罪（240後段）の成否を検討することになる。ここでは、相続権が「財産上……の利益」（236Ⅱ）に該当するかが問題となる（**論点**「財産上……の利益」（236Ⅱ）の意義）。

総合 206 頁 論証 89 頁

財産上の利益の移転は、暴行・脅迫から直接生じていなければならないと解されており、取得において一定の手続が要求される相続権は具体性・直接性を欠くと解されている（東京高判平元.2.27）。

- 2 したがって、甲には殺人罪（199）が成立するにとどまる。

第2 Bに対する罪責

甲は、Cに依頼をして、Bを殺害している。

甲は、具体的な犯行計画等は指示しておらず、Cが自主的に行動したと考えられるから、甲にはBに対する殺人罪の教唆犯（61Ⅰ）が成立する。

第3 Cに対する罪責

甲は、Cからの500万円の請求を免れるために、Cを殺害しているため、ここでも強盗殺人罪を検討することになる。なお、甲はCに対して有形力を行使していないが、判例（大判大3.6.24）は、「殺害行為は被害者の反抗を全然不能ならしむるものなるを以て暴行なること論を俟たず」として、究極の反抗抑圧手段である被害者の殺害は実質的に暴行を包含しているとする立場を採っているから、「暴行」に当たる。

まず、本件において、Cの500万円の請求権はB殺害の対価であるため、不法契約に基づく利益（民事法上保護に値しない利益）が「財産上……の利益」に当たるかを検討する必要がある（**論点**「財産上……の利益」（236Ⅱ）の意義）。

総合 206 頁 論証 89 頁

この点について、最決昭61.11.18【百選Ⅱ40】の調査官解説は、「刑法の財産罪の趣旨は、個々の被害者の具体的財産被害の填補にあるのではなく、財産法秩序が不法手段により乱されることを予防することを通じて、私人の財産上の正当な権利・利益を保護することにあるのであるから、被害者に具体的には法的保護に値する利益がない場合であっても、財産権侵害の外形を備え、正当な財産権を侵害する一般的危険性を備えた行為は、財産罪の処罰対象とするのが相当である。」とした上で、「禁制品が奪取罪の客体になると解するのと同じ趣旨で、その返還を免れるという利益は2項強盗罪等の2項犯罪の客体になると解すべき」であると述べている。これは、民事法上保護に値しない利益であっても、刑事法上は保護に値する（場合がある）ことを認めるものである。

次に、2項強盗における処分行為の要否も問題となる（**論点**強盗利得罪における処分行為の要否 **論** 司R2J1BH6-2）。

総合 207 頁 論証 90 頁

この点について、判例（最判昭32.9.13【百選Ⅱ39】）は、「〔刑法〕236条2項の罪は1項の罪と同じく処罰すべきものと規定され1項の罪とは不法利得と財物強取とを異にする外、その構成要素に何らの差異がなく、1項の罪におけると同じく相手方の反抗を抑圧すべき暴行、脅

迫の手段を用いて財産上不法利得するをもって足り、必ずしも相手方の意思による処分行為を強制することを要するものではない。」として、処分行為を不要とする立場に立っている。

もっとも、2項強盗罪の成立範囲を限定するため、債権者による当該債務の履行の追及が事実上不可能若しくは著しく困難な状態になるという現実には財産上の利益を取得するとみられる事情が必要であるなどと解されている。

さらに、強盗殺人罪の成否を検討するに当たり、死の結果に故意ある場合の処理についても触れておく必要がある（**論点** 強盗致死傷罪において、死傷の結果に故意ある場合 ■18H12-1）。

この点について、判例は、殺人の故意ある場合にも、同条後段を適用するという立場を採っている（最判昭32.8.1）。

総論 214 頁 論証 96 頁

答案構成

第1 Aに対する罪責

- 1 強盗殺人罪（240後段）の成否が問題となる
↓
- 2 相続権が「財産上……の利益」（236Ⅱ）に該当するか
↓
否定説
↓
- 3 殺人罪（199）成立

第2 Bに対する罪責

殺人罪の教唆犯（61Ⅰ）成立

第3 Cに対する罪責

- 1 強盗殺人罪の成否が問題となる
↓
「暴行」
↓
「財産上……の利益」
↓
民法上不法な利益も含まれるか
↓
含まれる
↓
- 2 処分行為の要否
↓
処分行為は不要だが、債権者による当該債務の追及が事実上不可能
又は著しく困難になることは必要
↓
あてはめ
↓
- 3 死亡の結果に故意ある場合を含む
↓
甲に強盗殺人罪が成立する

第4 罪数

①Aに対する殺人罪、②Bに対する殺人罪の教唆、③Cに対する強盗殺人罪が成立し、これらは併合罪（45前段）となる

第1 Aに対する罪責

1 Aを殺して、相続によりAの財産を得ようと考え、殺意を持ってAを殺害した行為について、強盗殺人罪（240条後段）の成立が考えられる。

2 そこで、前提となる強盗罪（236条2項）の成否を検討するに、本件において、甲はAの遺産を相続するためにAを殺害しているが、相続権が「財産上……の利益」に該当するかが問題となる。

「財産上……の利益」は、1項強盗との均衡から、利益の取得が財物の占有移転と同視できるだけのものでなければならず、利益を取得したといえるためには、具体的・直接的な利益を現実に取得したといえなければならない。

そうだとすれば、一般的にみて、取得において一定の手続が要求される相続権は、具体性・直接性を欠き「財産上……の利益」とは評価できず、強盗として論ずることはできない。

本件でも、相続財産の取得に一定の手続が必要とされるのは変わらないと思われるので、具体性・直接性が認められない。

したがって、相続権は「財産上……の利益」には当たらない。

3 以上から、甲には強盗（殺人）罪は成立せず、「人を殺した」ものとして、殺人罪（199条）が成立するにとどまる。

第2 Bに対する罪責

甲は、Cに対し、「Bに脅されている。Bを殺してくれたら500万円払うから、お願いできないか。」と言ったところ、Cは、これを了承

1

し、Bを殺害している。

甲はCをしてB殺害の犯意を惹起させているから、「人を教唆して犯罪を実行させた」ものとして、殺人罪の教唆犯（61条1項）が成立する。

なお、Cは、B殺害の具体的な計画を自分で考えた上で、その計画どおりにBを殺害したのであるから、甲とCとの間には、B殺害にかかる具体的な意思連絡がなく、共同正犯（60条）は成立しない。

第3 Cに対する罪責

1(1) 甲は、Cからの500万円の請求を免れるために、殺意を持ってCを殺害している。そこで、強盗殺人罪の成立が考えられる。

ここでも、前提となる強盗罪（236条2項）の成否を検討する。

(2) 甲は、Cに対して有形力の行使を行っていないが、殺害行為は究極の反抗抑圧行為であるから「暴行」に当たる。

(3) 次に、Cの500万円の請求はB殺害の対価となっており、かかる利益は民法上不法なものである。そうだとすれば、「財産上……の利益」に当たらないのではないか。

この点について、民事法的には法的保護に値する利益がない場合であっても、不法な手段によって財産法秩序を乱す行為を容認することは、私人の正当な権利・利益の実現を不能ならしめることになる。

(4) したがって、民事実体法上不法な利益であっても、刑法上は「財産上……の利益」に当たると解すべきである。

2(1) では、「暴行……を用いて」（236条1項）「財産上不法の利益

2

を得」(同条2項)といえるためには、処分行為は必要か。

2項強盗罪は、被害者の意思を抑圧して財産上の利益を強取する犯罪類型である以上、同罪における「暴行」は処分行為に向けられたものである必要はないと解する。

もっとも、上記のように、1項強盗罪との均衡を図り、利益移転時期を明確化する必要があるから、債権者による当該債務の追及が事実上不可能又は著しく困難になるという、現実には財産上の利益を取得するとみられる事情が必要と考える。

(2) 本件では、Cに債権を追及可能な相続人がいるなどの事情もなく、500万円の債務の追及は事実上不可能又は著しく困難になるといえる。

以上から、甲は「暴行……を用いて」「財産上不法の利益を得」たものとして、2項強盗罪が成立する。

3 また、240条には結果的加重犯の条文にみられる「よって」の文言がないから、殺人の故意ある場合を本条に含めることに問題はない。

以上から、甲には強盗殺人罪が成立する。

第4 罪数

甲には①Aに対する殺人罪、②Bに対する殺人罪の教唆、③Cに対する強盗殺人罪が成立し、これらは併合罪(45条前段)となる。

以上